

1500410-35.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... pública, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, que se prolonga no tempo, a detenção de indivíduo praticando uma das dezoito condutas nucleares do tipo autoriza a prisão em flagrante, na forma do artigo 301 do CPP. A propósito. Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Conduta desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

Vara Criminal da Comarca de Itatiba

Av. Barão de Itapema, 181 - Centro - Cep: 13250-902 - Itatiba - SP

Fone: (11) 2299-1206 / e-mail: itatibacr@tjsp.jus.br

Processo nº 1500410-35.2022.8.26.0544

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO,
DEBATES E JULGAMENTO

Ação: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autora: JUSTIÇA PÚBLICA

Representante do Ministério Público: Dra. Ana Carolina Martins Valente

Réu(s): ROBSON MARCOS MACIEL DA SILVA

Advogado(s): Matheus Marcelo Teodoro da Costa, OAB 434784/SP

Testemunhas: GM THIAGO SOARES LOPES DA FONSECA e GM Júlio Cesar Mesquita

Vítima: Saúde Pública

Aos 19/09/2022, às 10:00h, nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, seguindo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça e na forma do Comunicado CG nº 284/2020, realizou-se audiência por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente, com a concordância das partes e envolvidos no ato processual.

Prévia e reservadamente reuniram-se o(s) acusado(s) e seu(s) Defensor(es) por intermédio de reunião, via ferramenta Microsoft Teams.

Pelas partes foi manifestada a concordância com a utilização de recurso de gravação audiovisual para a colheita dos depoimentos, dispensada a transcrição, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 405 do CPP e item 77.5 das NSCGJ. Após, instalou-se formalmente a audiência, presentes na videoconferência o MM. Juiz de Direito Dr. Ezaú Messias dos Santos, o Assistente Judiciário ao final nomeado, a Promotora de Justiça, Dra. Ana Carolina Martins Valente, o réu ROBSON MARCOS MACIEL DA SILVA, o advogado, Dr. Matheus Marcelo Teodoro da Costa, OAB 434784/SP, e as testemunhas de acusação, GMTHIAGO SOARES LOPES DA FONSECA e GM Júlio Cesar Mesquita.

Ao início dos trabalhos, o MM. Juiz procedeu, primeiramente, ao interrogatório do réu com a concordância do MP e da Defesa, observadas as formalidades do artigo 185, do CPP. Após, passou a tomar o depoimento das testemunhas, que ingressaram individualmente na reunião de videoconferência, preservada a incomunicabilidade e observadas as formalidades legais.

A seguir, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução processual e, passando-se aos debates, concedeu a palavra às partes, que apresentaram as razões finais oralmente, tudo gravado pelo sistema audiovisual.

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: VISTOS. ROBSON MARCOS MACIEL DA

SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 15h10min, na Avenida Japão nº 290, Jardim das Nações, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, dezoito porções de crack e cinco porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, guardas municipais abordaram o réu em local conhecido como ponto de venda de drogas e ao avistar a equipe lançou objetos ao solo e tentou se evadir, sendo detido e em revista pessoal foram encontrados em seu poder R\$60,00 e porções de crack e maconha. Concedida a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 47/48), o réu foi notificado e citado (fls.92/93) e pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 104/114), sendo recebida a denúncia (fls. 137/139). Nesta audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, e a Defesa, em essência, a absolvição por insuficiência de provas. Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO. O caso é de condenação. A materialidade está demonstrada nos laudos de constatação provisória (fls. 22/24) e de exame químico-toxicológico (fls. 95/97), que resultaram positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas. O réu, quando da lavratura do flagrante, disse que um amigo de nome Elias pediu que ele "segurar" a biqueira para poder ir a um churrasco, assumindo que chegou a vender R\$ 40,00 em drogas, mas ao ver a viatura, assustado, tentou fugir, sem sucesso. Em juízo, admitiu que, passando por dificuldades financeiras, sendo usuário de drogas, aceitou trabalhar uma tarde numa biqueira para adquirir algum dinheiro, mas, ao ver a viatura, se assustou, saiu correndo e foi detido, sendo encontradas em seu poder porções de drogas e dinheiro da venda. Os guardas municipais confirmaram a abordagem do réu em local conhecido como ponto de venda de drogas e na revista encontraram porções de maconha, crack e R\$ 60,00, admitindo ele que estava no tráfico. O GM Soares esclareceu que chamou a atenção um indivíduo abaixado num local tido como ponto de venda de drogas, o qual saiu correndo ao ver a viatura, o perseguiu e o deteve. O GM Mesquita disse que o réu, ao ser detido com drogas, admitiu que aceitou vender drogas porque precisa de dinheiro. As declarações firmadas por testemunhas confirmam que o réu era usuário de drogas e passava por percalços financeiros. Diante de tão cruel, doloroso e verdadeiro quadro, corroborada a confissão pelos demais elementos de convencimento, não resta outra solução a não ser condenar mais um desgraçado que se presta a vender drogas para enriquecer o verdadeiro traficante, que, certamente, outro imediatamente colocou no lugar porque a "lojinha" não pode parar. Por fim, ao revés do alegado pela defesa, conquanto não se descure que não raras vezes há excessos na atuação dos guardas municipais, tanto havia fundadas razões para a abordagem que com o réu foram achadas drogas. Vale dizer, a busca pessoal não está maculada de qualquer vício, uma vez que trata de situação de flagrante permanente justamente porque o réu trazia as drogas consigo para a venda, como admitiu. Não há, nesta toada, que se falar em ilicitude da prova, enfatizando que, conquanto não se olvide que não raro a Guarda Municipal exorbite sua atribuição legal de vigilância de bens, serviços e instalações públicas municipais, usurpando competência constitucional das polícias civil e militar, diligenciando, investigando e reprimindo condutas, excedendo seu escopo institucional de agente auxiliar e de cooperação com as forças de segurança pública, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, que se prolonga no tempo, a detenção de indivíduo praticando uma das dezoito condutas nucleares do tipo autoriza a prisão em flagrante, na forma do artigo 301 do CPP. A propósito. Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Conduta desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Recursos do Ministério Público e da defesa técnica - Defesa sustenta a nulidade do feito, diante da atuação ilegal da guarda civil na prisão em flagrante e apreensão das drogas - Não há que se falar em prova ilícita, porquanto a atuação da guarda civil se limitou a checar a veracidade de delação anônima, não se verificando atos típicos de investigação policial - Mérito - Acusação pede a condenação pelo crime de tráfico de drogas - Pouca quantidade de drogas, sem provas

da prática de atos mercantis - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500530-78.2020.8.26.0599; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 05/10/2021). Reconhecidas, assim, a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena. Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando que a diminuta quantidade de droga apreendida evidencia o comércio rasteiro para sustento do desgraçado vício, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, na medida em que a circunstância atenuante genérica da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada ao delito. Sendo o réu primário, não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa. À mingua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal. Ante as penas fixadas e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto é o acusado primário, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo. A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente permitiram a manutenção das penas-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime. A propósito: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DE DROGA DE MENOR PODENTE CIAL LESIVO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICABILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. In casu, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a Corte a quo não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre a paciente e o corréu, tendo consignado que "o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06 pressupõe a reunião de propósitos para a exploração do comércio ilegal de drogas, não sendo a estabilidade elemento de sua qualificação, estando, portanto, em desacordo com a jurisprudência firmada por esta Corte. 4. No termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 5.

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei de Drogas, e tratando-se de pequena quantidade de droga de menor potencial lesivo (75,4g de maconha), é desproporcional e desarrazoada a exasperação da pena-base em 1/6, visto que não há outras circunstâncias desfavoráveis, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

6. Tendo a pena-base sido redimensionada ao mínimo legal (5 anos), tornou-se inviável a incidência da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, nos termos da Súmula 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 7. Nos termos do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 8. No caso, ao contrário do firmado pelo Tribunal de origem, entende-se que a quantidade do entorpecente apreendido não se mostra elevada, fazendo jus a paciente à aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, sobretudo quando considerada sua primariedade, bons antecedentes e a ausência, no caso concreto, de elementos indicativos de que integre organização criminosa ou de que se dedique à criminalidade. 9. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é manifestamente ilegal a imposição do regime prisional mais severo com base, exclusivamente, no disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES. 10. Estabelecida a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, verificada a primariedade da agente e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o cumprimento inicial em regime aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. 11. Preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença condenatória, de forma a absolver a paciente pelo delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, fixar a pena-base no mínimo legal para o delito de tráfico e aplicar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, ficando a reprimenda final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa, bem para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da execução. (HC nº 355.047 - SP (2016/0112859-0); Relator Min. Ribeiro Dantas - Brasília (DF), 1º de setembro de 2016, g.n.). Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade. Por fim, em caso de descumprimento das penas substitutivas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa, na esteira do entendimento dos tribunais superiores conforme jurisprudência acima mencionada no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ROBSON MARCOS MACIEL DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo as penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do

Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo em que ficou recluso. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça. Determino a perda do valor apreendido em favor da União. Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas. P. I. C. Itatiba, 19 de setembro de 2022. EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS. Juiz de Direito. Sentença publicada em audiência.

O MM. Juiz assina este termo em nome de todos os presentes, os quais tomaram ciência de seu conteúdo e não apresentaram impugnação, portanto, saem as partes presentes devidamente intimadas. Nada mais. Eu, ____ (Thiago André Busso), escrevente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Link de acesso à mídia, devendo ser copiado e colado diretamente no navegador:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tbusso_tjsp_jus_br/EVF2VlBLt1BHuoARbvhbeeoBU3opnrTNeuEsUYs4Ci76hQ?e=Iwt8oP